

1500253-60.2019.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... pela desclassificação do delito de tráfico para a figura do artigo 28, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Quanto ao artigo 14 da lei 10.826/2003 afirmou desconhecimento da lei (f.658/683).

Por sua vez, a defesa de VINICIUS FERNANDO GOMES pugnou pela absolvição do acusado da imputação da prática do delito de tráfico drogas, nos moldes do art. 386, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500253-60.2019.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500253-60.2019.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministério Público

Réu:

Vinicius Fernando Gomes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra VINÍCIUS FERNANDO GOMES e GABRIEL TREVISONI VAZ, pela prática dos crimes dos artigos 33, c.c. o artigo 40, incisos III e VI da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 29 do Código Penal; e GABRIEL TREVISONI VAZ como incurso no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 06 de outubro de 2019, por volta de 00h 05, na Rodovia SPA 381/330, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, nas imediações de recinto onde se realiza diversão de qualquer natureza, VINÍCIUS e GABRIEL, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 09 (nove) porções, com peso aproximado de 2,03 gramas de "cocaína", e porções contendo 3,01 gramas; 16,21 gramas, 21,35 gramas e 0,77 gramas de "maconha", conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, com a prática do tráfico de drogas, os acusados envolveram e visaram

atingir as adolescentes L. A. P. P. e J. B. S. M.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, GABRIEL TREVISONI VAZ, portava e transportava arma de fogo consistente em um revólver da marca "Taurus", nº 304345, com dois cartuchos da marca CBC, todos calibre 32, de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (f. 01/03).

A denúncia veio amparada em inquérito policial conduzido pela Polícia Civil (f. 04/152).

Os acusados foram presos em flagrante delito. Realizada audiência de custódia, oportunidade em que foram homologadas as prisões em flagrante e convertidas em preventiva (f.74/77)

Os acusados apresentaram defesa prévia (f. 187/199 e 231/254).

Habeas Corpus concedeu liberdade provisória ao acusado VINICIUS (f.259/263). Decisão de f. 255/256 recebeu a denúncia e aprazou audiência de instrução e julgamento.

Decisão de f.405/408 concedeu liberdade provisória ao acusado GABRIEL.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogados os acusados.

Em suas alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da inicial acusatória(f. 643/657).

A defesa do acusado GABRIEL TREVISONI VAZ alegou, preliminarmente, inépcia da denúncia. No mérito alegou ilicitude das provas produzidas, em decorrência da violação do direito ao silêncio, bem como violação de domicílio. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de tráfico para a figura do artigo 28, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Quanto ao artigo 14 da lei 10.826/2003 afirmou desconhecimento da lei (f.658/683).

Por sua vez, a defesa de VINICIUS FERNANDO GOMES pugnou pela absolvição do acusado da imputação da prática do delito de tráfico drogas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, por falta de provas. Pleiteou os benefícios da pena e reconhecimento da confissão espontânea. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento das causas de aumento (f. 694/701).

É o breve relatório. Vistos e examinados os autos, passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, afasto a alegação da defesa de inépcia da denúncia, porque não pode ser reputada inepta a exordial acusatória elaborada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual foi observado o devido processo legal. Motivo pelo qual torna-se impossível o reconhecimento da preliminar alegada.

Rechaço a arguição de nulidade da prova recolhida em diligência de busca por ofensa ao direito de inviolabilidade asilar, a considerar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e, no caso concreto, havia fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito penal no interior do imóvel, pelos que os diligentes policiais agiram com acerto ao promover por ação própria a diligência. Com efeito,

não há ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, porque os acusados estavam em situação de flagrância e havia fundada suspeita da ocorrência da infração penal, porque os acusados foram encontrados na posse de drogas, de dinheiro e de arma de fogo, agindo em comparsaria, inclusive com adolescentes, o que traduz fundada suspeita apta a autorizar a busca domiciliar, o que, registre-se, estava em linha com a própria confissão do acusado, que confessou o depósito das drogas nos locais onde realizada a diligência policial, como é possível extrair dos depoimentos dos militares na fase extrajudicial.

Segundo prescreve o art. 5º, XI, da Carta Maior, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Como se percebe, há 4 (quatro) exceções à inviolabilidade do domicílio: a) flagrante delito; b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. Convém lembrar, também, que, de acordo com o magistério jurisprudencial do STF, o conceito de "casa" é amplo, abarcando (i) qualquer compartimento habitado (casa, apartamento, trailer, barraca); (ii) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva (hotel, apart-hotel, pensão); ou (iii) qualquer compartimento privado onde alguém exerça profissão ou atividade, incluindo as pessoas jurídicas (Bernardes e Ferreira, in Direito Constitucional - Tomo II). De outra banda, é majoritário, outrossim, o entendimento de que o termo "dia", para fins dessa garantia constitucional, segue critério físico-astronômico, compreendendo o interregno que vai da aurora ao crepúsculo.

O Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que a exceção à inviolabilidade domiciliar em razão de flagrante delito - que, recorde-se, pode ocorrer mesmo no período noturno - deve estar arrimada em fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º), devidamente justificadas 'a posteriori', hábeis a indicar que no interior na casa se está praticando algum crime, é dizer, em estado de flagrante delito. Com isso, quis o Supremo equacionar o direito dos cidadãos e a proteção aos agentes de segurança pública. Noutras palavras, mesmo que durante a invasão domiciliar não se tenha constatado a ocorrência de um crime em flagrante, não haverá ilicitude na conduta dos agentes policiais se apresentarem as fundadas razões que os levaram a ingressar naquela casa, o que, sem dúvida, deve ser objeto de controle - mesmo que 'a posteriori' - por parte da própria polícia e, claro, pelo Ministério Público (a quem compete exercer o controle externo da atividade policial, nos termos do art. 129, VII, da CF) ou mesmo pelo Judiciário, ao analisar-se a legitimidade de eventual prova colhida durante essa entrada à residência.

Vejamos a ementa do referido julgado:

EMENTA: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa

Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No caso concreto, constato, no controle judicial posterior de validade dos atos de investigação, que havia fundadas razões para a ação policial, porque: a) havia delação anônima minuciosa a respeito da dinâmica do crime em festa de grande movimentação de pessoas; b) os policiais constataram que os acusados estavam nas circunstâncias registradas na denúncia anônima, inclusive com drogas, dinheiro, arma de fogo e adolescentes envolvidos; c) a apreensão de drogas na posse direta dos acusados; d) a confissão do acusado de que conservava depósito de drogas na casa. Portanto, concluo que os policiais agiram com acerto. Nesse contexto, a considerar que o crime de tráfico de drogas é permanente e que havia fundadas razões da ocorrência do tráfico, nos exatos termos dos parâmetros delineados pelo RE n. 603.616, declaro a validade das provas apresentadas pela Polícia Militar

De igual modo, é o caso de britar a alegação de violação do direito ao silêncio, posto que não é exigido dos policiais brasileiros que façam essa advertência durante a abordagem policial. O direito de ser informado sobre o direito de ficar em silêncio não se aplica às entrevistas informais feitas pelos policiais durante abordagens nas ruas, uma vez que não há acusado ou investigado. Nesse sentido, cito arestos do Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 149 DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA OITIVA DE TODOS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. "CONFISSÃO" EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. Nos termos do art. 186, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 5º, LXIII, da Constituição, o alerta sobre o direito ao silêncio é garantido ao preso e ao acusado de uma prática delitiva. A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração do prejuízo por quem o alega. 8. No caso em análise, o recorrente não logrou demonstrar o prejuízo suportado em seu direito de ampla defesa ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de permanecer calado, quando da abordagem policial. (AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)"

"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, NUMERAÇÃO RASPADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE

DA VIA ELEITA.ABORDAGEM POLICIAL. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. RÉU QUE PERMANECEU CALADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. ADVERTÊNCIA CONTIDA NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO.(...).5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017)"

Logo, as preliminares hasteadas não merecem prosperar.

Não havendo outras preliminares e incidentes pendentes de saneamento, pelo que passo a julgar a imputação formulada pelo Ministério Público.

A fim de evitar repetições desnecessárias, transcrevo o teor da prova oral.

A testemunha MARCOS ANTONIO GOMES FILHO, policial militar , ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos receberam a informação sobre um evento que ocorria frequentemente no mesmo local, mediante denúncias vinculadas ao evento, com relação a presença de menores de idade e de tráfico de entorpecentes. Ao abordarem o veículo ocupado pelos acusados, notou que VINICIUS atirou algo pela janela do carro. Durante o procedimento GABRIEL, que estava no banco de passageiro, retirou algo de sua cintura e, com o pé, empurrou para debaixo do banco. Estavam no veículo, três homens e duas adolescentes. Após o procedimento de revista pessoal, um dos agentes dirigiu-se até o local onde VINICIUS arremessou o objeto pela janela e localizou uma embalagem contendo 9 (nove) cápsulas de cocaína. VINICIUS carregava consigo a quantia de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), enquanto GABRIEL tinha a quantia de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais) e uma porção de maconha. Durante vistoria pelo veículo uma arma foi localizada no local em que GABRIEL retirou algo de sua cintura. GABRIEL admitiu a propriedade do objeto e alegou que não pretendia fazer mal a alguém com o item, no entanto o portava pois havia tido problemas com algumas pessoas em São Joaquim da Barra-SP e o utilizaria para defender-se caso necessário, revelou ainda que em sua casa, na cidade de IPUÃ- SP os policiais encontrariam mais drogas. Ao total localizaram mais de 30 gramas de maconha. Os outros ocupantes do veículo relataram desconhecimento com relação aos itens localizados (mídia digital).

A testemunha TIAGO ROBERTO TOGNATI SILVEIRA, policial militar, ouvido em juízo, relatou que no após o recebimento de denúncias, com relação a uma festa que costumeiramente ocorre no mesmo local, com grande consumo de drogas, deslocaram-se até a localidade, no momento em que se aproximaram do veículo, notaram que VINICIUS arremessou algo pela janela. GABRIEL pegou uma arma de fogo que estava em sua cintura, colocou-a no assoalho do veículo e, com os pés, empurrou para debaixo do banco. O objeto dispensado por VINICIUS, trata-se de uma embalagem contendo 9 (nove) cápsulas de cocaína de cores distintas entre si, além de uma porção de maconha. Com JULIANO, que era o condutor do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Com GABRIEL, foi localizada uma porção de maconha, além da quantia de R\$202,00 (duzentos e dois reais). GABRIEL, quando indagado, admitiu ser o proprietário da arma de fogo e revelou que, na casa dele e de sua irmã, encontrariam mais 35g de maconha. Outros agentes dirigiram-se até a residência,

localizada na cidade de IPUÃ-SP, onde encontraram os entorpecentes no local apontado pelo acusado. Com VINICIUS localizaram a quantia de R\$43,00 (quarenta e três reais), o acusado negou que teria dispensado os entorpecentes, assim como negou a propriedade das drogas. GABRIEL revelou que estava com a arma de fogo pois em outra situação teve desentendimentos com pessoas de São Joaquim da Barra, então levou o objeto para o evento para defender-se caso necessário. JULIANO narrou que iria apenas levar os ocupantes do veículo até o local do evento, as menores de idade que estavam no veículo disseram desconhecer os itens localizados. GABRIEL contribuiu com os policiais. A abordagem ocorreu na entrada do condomínio onde o evento iria ocorrer (mídia digital).

A testemunha J. B. S. M., ouvida em juízo, declarou que no dia dos fatos havia ingerido bebidas alcoólicas e não se recorda ao certo o que ocorreu no episódio em questão (mídia digital).

O informante JULIANO BRUNO ALVES DE EVANGELISTA, irmão de VINÍCIUS, ouvido em juízo, declarou que VINÍCIUS e GABRIEL pediram para os levar até a festa. Quando estavam chegando, foram abordados pelos policiais. Não tinha conhecimento da existência das drogas nem da arma de fogo. Não soube informar com quem a droga foi encontrada. VINÍCIUS era usuário de drogas, mas recentemente começou a trabalhar e deixou o vício. Pelo que ficou sabendo, a droga pertencia à adolescente Lauane. Não visualizou GABRIEL dispensando nada (mídia digital).

A informante RAQUEL FRANCISCO DA SILVA, ouvida em juízo, irmã de GABRIEL, declarou que o irmão morava em sua residência, ela tinha conhecimento sobre o consumo de drogas feito por GABRIEL. A mãe do acusado encontrou a arma de fogo e pediu para o filho "sumir" com o objeto. (mídia digital)

O acusado VINICIUS FERNANDO GOMES, interrogado em juízo, narrou não ter conhecimento de que os entorpecentes estavam no interior do veículo, não arremessou o objeto para fora do carro. A janela próxima ao acento em que estava não abria, desse modo não haveria possibilidade de arremessar algo para fora do veículo. Disse que a adolescente L. A. P. P. que é usuária de entorpecentes, foi a responsável por arremessar o objeto para fora do veículo. Admitiu ser usuário de entorpecentes e que já fez uso deste tipo de substância em conjunto com GABRIEL. O dinheiro localizado com ele provém de seu trabalho como mecânico. JULIANO iria apenas levar os acusados até o evento. As adolescentes que estavam com eles pediram apenas carona até a festa. A adolescente L. A. P. P. admitiu que lançou o entorpecentes para fora do veículo e que utilizaria a substância para consumo próprio. Não tem conhecimento sobre desentendimentos de GABRIEL com pessoas de São Joaquim da Barra-SP (mídia digital) .

O acusado GABRIEL TREVISONI VAZ, interrogado em juízo, declarou que comprou a arma no dia dos fatos, mas sua mãe encontrou o objeto e pediu para ele se livrar do artefato. A arma de fogo foi adquirida com um caminhoneiro. Estava portando a arma no dia do ocorrido pois tinha a intenção de descartá-la em um rio próximo ao local do evento. Durante a tarde, encontrou-se com VINICIUS que o convidou para ir até o evento. A maconha encontrada era para seu consumo. Não sabe a quem pertencia a cocaína. O dinheiro encontrado com ele, era referente a parte de seu salário. Não sabia que as adolescentes iriam ao evento. Cada ocupante pagou a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) pela carona até o evento. Relatou aos policiais que adquiriu a arma pois era algo que sempre desejou. A quantidade de maconha encontrada pela polícia era para seu consumo próprio, seria utilizada para seu consumo mensal. (mídia digital)

Esse é o teor da prova oral.

1- QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RÉUS VINICIUS E GABRIEL

O Ministério Público acusa VINÍCIUS FERNANDO GOMES e GABRIEL TREVISONI VAZ de praticarem, em tese, o crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que cuida do denominado delito de "tráfico de drogas" possui a seguinte redação:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A acusação é parcialmente procedente, uma vez que não restou provado o tráfico de drogas, mas sim a posse de droga para consumo penal, pelo que urge a desclassificação.

A materialidade do delito está provada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito (f. 04//06), laudo de constatação (f.20/23), o boletim de ocorrência (f. 24/30), o auto de exibição e apreensão (f.31/32), e dos exames toxicológicos de f. 156/157, 162/163 e 365/366 e por toda a prova oral colhido sob o crivo do contraditório. Consigne-se, por fim, que a materialidade é fato incontroverso.

O laudo definitivo de f. 365/366 evidenciou a presença dos compostos químicos "maconha" e "cocaína", para as amostras contidas nas substâncias apreendidas, respectivamente, com os acusados GABRIEL e VINICIUS. As substâncias encontram-se relacionadas na Lista "F" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, é fato incontroverso que os acusados estavam na posse das drogas, mas não há provas de que eles estivessem praticando o tráfico de drogas, pelo contrário, há elementos contundentes de que eles são usuário de drogas, impondo a desclassificação.

Portanto, há provas de que os acusados são usuários de drogas.

Nada de relevante foi produzido que pudesse vincular os acusados ao tráfico de drogas, repousando a acusação em meras conjecturas e suspeitas frágeis. Dessa forma, a acusação ficou assentada exclusivamente no depoimento dos policiais, que não viram os acusados engajados no tráfico, vendendo drogas.

As delações anônimas recebidas pelos policiais, que, registre-se, são meras "informações de inteligência" e não prova em sentido estrito, não reportaram o envolvimento direto dos acusados com o tráfico. As delações anônimas reportaram apenas o tráfico de drogas numa festa de adolescentes e jovens, alegações genéricas e corriqueiras.

Agrego, ainda, que a quantidade de drogas e dinheiro apreendidos é de pequena monta, tudo convergindo no sentido de que não há materialidade do crime de tráfico.

Assim, perlustrando as provas recolhidas, verifico que foram apreendidas pequenas porções de drogas. Conforme os depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais não visualizaram os investigados manipulando as drogas ou as vendendo a terceiros. Os acusados estavam com seus amigos em direção a uma festa de jovens, com poucas drogas, ou seja, é razoável a tese de que eles possuíam as drogas para consumo próprio.

As delações anônimas foram importantes ferramentas para orientar o trabalho de investigação policial, mas não podem suprir a falta de investigação. Os agentes

policiais deveriam coordenar um trabalho de apuração mais detalhado, mediante campanhas, filmagens, interceptação telefônica e várias outras técnicas ordinárias e especiais de investigação e etc.

Portanto, concluo que não há provas suficientes de que os acusados estavam traficando drogas.

A cláusula do devido processo legal e o princípio da presunção de inocência exigem que o órgão oficial de acusação suporte o inteiro ônus da prova de culpabilidade do réu, além de uma dúvida razoável (beyond a reasonable doubt). A mera dúvida resolve o processo em favor do acusado. "A presunção de inocência, princípio cardinal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

No caso em julgamento, não há como afirmar se houve ou não o tráfico de drogas, mas há uma inegável dúvida razoável a respeito da procedência da acusação. Se os indícios que outrora sustentaram o envolvimento dos acusados nos fatos delituosos imputados na denúncia não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, notadamente em observância aos princípios do devido processo legal e do estado de não culpabilidade. Condenação criminal exige provas contundentes, sérias, robustas, ao passo que nestes autos nenhuma prova foi produzida no sentido da procedência.

A considerar que os acusados foram surpreendidos na posse de droga é o caso de promover a desclassificação e condená-los pelo crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

2- QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003 - RÉU GABRIEL

O Ministério Público imputa, ainda, ao acusado GABRIEL TREVISONI VAZ a prática da conduta típica descrita no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, que dispõe:

"Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente."

Assim, no caso, materialidade do porte da arma de fogo ficou assentada pela prisão em flagrante (f. 04//06), laudo de constatação (f.20/23), o boletim de ocorrência (f. 24/30), o auto de exibição e apreensão (f.31/32), pelo laudo pericial de f. 350/355, que concluiu pela eficácia dos artefatos para efetuar disparos, tudo somado prova oral colhida em juízo.

A autoria pode ser imputada com segurança ao acusado, que confessou o crime em tela, nos exatos termos da denúncia. Importante consignar que a confissão do acusado está em harmonia com as demais provas, especialmente pela prisão em flagrante delito, bem como pelo depoimento das testemunhas, o que satisfaz o artigo 197 do Código de Processo Penal.

No que tange ao depoimento prestado por agentes policiais, entendo que não merece

amparo qualquer tentativa de desqualificação, pois os testemunhos apresentados em juízo por tais pessoas, assim como qualquer outro, merece credibilidade, especialmente se o processo se desenvolver em obediência aos ditames do contraditório e da ampla defesa, sendo exatamente este o caso dos autos. A este respeito, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

EMENTA: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. (...)." (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (g.n.)

Esclareço que o crime tipificado no artigo 14 da Lei n.º 10.826 /03 é de mera conduta (dispensa a ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade) e de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal), de sorte que a simples porte de arma de fogo de uso permitido já é capaz de configurá-lo, sendo irrelevante o fato de o agente não estar portando munições na mesma ocasião. Neste sentido:

(...) Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...) STJ - AgRg no HC 414581 / MS AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2017/0221364-9.

Ainda, não merece prosperar o alegado erro de proibição, porquanto, o "desconhecimento da lei é inescusável", conforme preconiza o artigo 21 do Código Penal. Destaco que o artigo define ser possível isentar de pena o agente que age por erro sobre a ilicitude do fato, frise-se, se inevitável ou se evitável (diminuindo a pena de um sexto a um terço), o que não se enquadra do presente caso, pois a versão apresentada pela defesa do acusado é inverossímil e destoa totalmente dos relatos testemunhais.

Erro de proibição é o erro que recai sobre a ilicitude da conduta, ou seja, "o agente sabe o que faz, porém não tem o conhecimento suficiente da antijuridicidade do fato. Esse erro recai sobre a existência de uma norma proibitiva, o autor desconhece que o fato é juridicamente desaprovado por uma norma que o pune (...) Exige-se do agente um conhecimento que seria exigível de qualquer pessoa (valoração na esfera do profano), mormente de que não tem formação jurídica" (João Paulo Martinelli e Leonardo Schmitt de Bem. Direito Penal. Parte Geral. 6ª edição. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2021, p. 827).

Por isso, "não é necessário ser um especialista ou bacharel em Direito. Basta se tratar de pessoa adulta, imputável, socializada, para ter ou atingir o conhecimento da antijuridicidade de determinado fato" (Artur de Souza e Carlos Japiassú. Curso de Direito Penal. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 312).

Tendo em vista que o acusado era adulto e imputável ao tempo do fato, socializado, é óbvio que ele sabia ou tinha condições de saber da proibição legal de porta arma de fogo sem autorização. O ordinário é que um adulto imputável saiba de uma proibição tão trivial como essa. Admitir o contrário, que é o extraordinário, é possível apenas com base em provas robustas e irrefutáveis, que não foram produzidas pela defesa. Interessante notar que os exemplos que os doutrinadores

apresentam sobre erro de proibição envolvem, em regra, estrangeiros viajando em países com leis exóticas e ermitões descendo montanhas após décadas de isolamento social.

Portanto, concluo que há farta prova de que o acusado efetivamente portava arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

III - DISPOSITIVO

Na confluência do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para: A) promover a desclassificação, e CONDENAR os acusados VINICIUS FERNANDO GOMES e GABRIEL TREVISONI VAZ nas sanções do artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006; B) CONDENAR o acusado GABRIEL TREVISONI VAZ como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal dos acusados, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

1) QUANTO AO ACUSADO VINICIUS FERNANDO GOMES

Todas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, pelo que fixo a pena de ADVERTÊNCIA, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

2) QUANTO AO ACUSADO GABRIEL TREVISONI VAZ

A) QUANTO À PENA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.434/06

Todas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, pelo que fixo a pena de ADVERTÊNCIA, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

B) QUANTO À PENA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003

Ausentes circunstâncias judiciais negativas (artigo 59 do Código Penal), fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la, perfilhando o entendimento consagrado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do Concurso Material: Diante do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido

Portanto fica a acusada definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e, a pena de ADVERTÊNCIA solução que é consentânea com o grau de reprovabilidade dos crimes praticados, necessária e suficiente para punição e prevenção do crime

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para autorizar a aplicação de regime mais gravoso, consoante súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e dosada pena superior a 1 (um) ano, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, na forma do artigo 44, § 2º do Código Penal.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º e 46 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistente em limitação de fim de semana e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 04 (quatro) salários-mínimos em favor de entidade credenciada perante o juízo. As condições da limitação de fim de semana serão aclaradas na fase de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar motivos que justifiquem a segregação cautelar (prisão preventiva) ou estabelecimento de medida cautelar diversa de prisão. Fixada pena a ser cumprida em regime aberto e com substituição por restritiva de direitos, a prisão preventiva afigura-se excessiva e desproporcional.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo *in albis*, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

d) Encaminhe-se a arma de fogo ao Exército, na forma do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA